

1500409-73.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E POR TRÁFICO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA AFASTADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500409-73.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500409-73.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3015281/2022 - 03º D.P. AMERICANA,

23297771 - 03º D.P. AMERICANA, 23297772 - 03º D.P. AMERICANA, 422/2022/346 - 03º

D.P. AMERICANA, 421/2022/346 - 03º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

GUSTAVO ELIAS BRITO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

GUSTAVO ELIAS BRITO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (10 porções de maconha, pesando 14,9g) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 35/36 foi recebida em 12 de julho de 2022 (fls. 84).

O réu foi citado (fls. 67), apresentando defesa (fls. 74/79).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 105/106).

Em seus memoriais (fls. 110/114), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

O Doutor Defensor do réu (fls. 116/121), requereu a absolvição por falta de provas, a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes, ou a aplicação do regime aberto.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelos laudos de fls. 29/31.

Não há dúvida que a droga "cannabis sativa", popularmente conhecida por "maconha" causa grave dano à incolumidade pública.

Nesse sentido, o editorial do jornal Folha de São Paulo do dia 21 de fevereiro de 2000:

MACONHA E DEPENDÊNCIA

Observa-se, em São Paulo, um aumento no número de casos de pessoas que procuram ajuda médica devido a complicações relacionadas à maconha. Trata-se de uma tendência ainda não quantificada em termos científicos, mas algumas clínicas registraram um acréscimo de 20% na demanda por esse atendimento. A Universidade Federal de São Paulo inaugurou, há três semanas, um ambulatório para esses pacientes. A maconha ainda está longe de constituir um problema de saúde pública, pelo menos um problema tão grande como os 10% de dependentes de álcool na população ou os inúmeros viciados em cocaína e crack. Isso, obviamente, não é razão para fechar os olhos para a questão.

Esse fenômeno com a maconha se explica, em parte, devido a uma mudança de paradigma na psiquiatria. Até meados dos anos 80, a dependência em relação a uma droga era avaliada basicamente pela tolerância (a necessidade de usar cada vez mais para obter o mesmo efeito) e pelo nível dos sintomas de abstinência (os efeitos físicos desagradáveis provocados pela retirada da droga). Em 87, a Associação Americana de Psiquiatria decidiu incluir também critérios psicossociais que indicassem um envolvimento sério do indivíduo com a substância para determinar se ele era ou não um dependente. Trocando em miúdos, pode ser considerado dependente todo aquele cujo envolvimento com alguma droga lhe provoca problemas sociais. Essa nova visão faz mais sentido. Afinal, o ser humano carrega em sua herança genética ou cultural uma fabulosa capacidade de ligar-se de forma patológica a determinados comportamentos, com ou sem drogas. É o caso, por exemplo, dos jogadores compulsivos. Aí, o próprio cérebro pode estar produzindo substâncias que o levam ao vício. São os chamados opióides endógenos. A literatura médica também registra episódios de dependências mais exóticos, como a de comer cenouras. Não se sabe ao certo se o beta-caroteno encontrado nesse vegetal tem potencial aditivo ou se o vício teria explicação em ritualizações. De todo modo, para a imensa maioria das pessoas, a cenoura é apenas um alimento, e saudável. Tudo está na forma como o indivíduo se relaciona com a droga, que pode ser patológica ou não, dependendo de inúmeras variáveis relacionadas à própria substância e à personalidade do usuário. O fato é que não faz mais tanto sentido falar em drogas leves. Droga é droga e muitas vezes tem consequências desastrosas. (os grifos são meus).

A autoria, relativo ao tráfico, é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hédio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

“Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os guardas municipais informaram que se encontravam em patrulhamento, e visualizaram o réu entregando algo para outro indivíduo, e recebendo algo em troca, sendo que ao avistarem a viatura, tomaram sentidos opostos, e que conseguiram alcançar o réu. Em abordagem, e em revista pessoal localizaram com o réu, nas vestes íntimas, cinco porções de maconha, além de outras porções idênticas e uma quantia de cerca de duzentos reais em dinheiro, em notas diversas, no bolso da bermuda. Indagado o réu negou a posse da substância entorpecente, e não soube explicar a origem do dinheiro. Por fim, informaram que o local é conhecido pelo tráfico de drogas, e já abordaram o réu em outras ocasiões, em situações semelhantes.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147,

todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - (...). (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar - Nulidade da sentença - Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares - Inocorrência - Decisão motivada - Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados - Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida - Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados - (...) - Sentença mantida - Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

APELAÇÃO - tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

Tráfico de entorpecentes - Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 21,5 gramas de cocaína, em pó - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes. (TJSP; Apelação Criminal 0003382-85.2013.8.26.0538; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito

Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).(...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

PROVA - Depoimento de Policiais - Valor:70(a) - Os testemunhos de Policiais possuem validade jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis, inexistindo qualquer vedação legal, sendo certo que, a simples condição de Policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (Apelação nº 1.179.625/0, Julgado em 22/02/2000, 14ª Câmara, Relator: Oldemar Azevedo, RJTACRIM 47/274)

A quantidade e forma de acondicionamento do tóxico apreendido, além da quantia em dinheiro localizada, evidencia a destinação de tráfico.

Ainda que se considere pequena a quantidade que o réu portava, já ficou patente que os "patrões" do tráfico costumam utilizar-se de pequenos traficantes para a venda. Confira-se à respeito, a matéria do Jornal "O Liberal" de Americana, no dia 21 de junho de 2009:

MICROTRAFICANTES VIRAM O PRINCIPAL FOCO

DA POLÍCIA - Os microtraficantes, como são chamadas pela polícia as pessoas que vendem pequenas quantidades de drogas, são o novo foco dos investigadores da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). "Esse tipo de traficante é como erva daninha. Quanto mais se prende, mais surge. Por isso temos de combatê-los. Queremos chegar no 'patrão' que está no topo e na base da pirâmide do tráfico", disse o delegado Marco Antonio Pozzetti, titular da DISE. Na semana passada, cinco microtraficantes foram presos. Esta forma de comércio foi criada pelos 'patrões' do tráfico para não sofrerem grandes baixas quando a polícia age. Cada micro fica no ponto de venda, conhecido como 'biqueira', com no máximo 20 unidades de entorpecentes (pedrinhas de crack, papelotes de cocaína e pequenos embrulhos de maconha). Eles são abastecidos pelos 'gatos' como os 'patrões' identificam os distribuidores.

"Os investigadores estão saindo às ruas à procura dos microtraficantes. Na quinta-feira, por exemplo, prendemos um que vendia drogas sentado em um sofá na calçada de sua casa, no Jardim Guanabara. Com ele nós encontramos seis pedrinhas de crack, dois pedacinhos de maconha e mais R\$ 30,00. É o exemplo do microtraficante. Ele estava com uma quantidade reduzida". Disse o delegado da DISE. "O surgimento dos microtraficantes é uma forma criada pelos 'patrões' do tráfico para evitar grandes tombos. Prendemos muitas pessoas e a quantidade de entorpecente apreendida é pequena. Assim, a 'biqueira' não sofre prejuízo", contou o delegado.

Uso próprio

As pessoas que são presas também tentam se beneficiar do artifício da pequena quantidade. Eles procuram provar, na Justiça, que o entorpecente pe para uso. Assim, tentam 'quebrar' a prisão de tráfico para uso de entorpecente. "A maioria alega que estava com aqueles papelotes ou pedrinhas par consumo próprio", afirmou um dos investigadores da DISE. Pozzetti instruiu os policiais a agirem nas duas pontas da pirâmide do tráfico. "Os micros estão na base e fazendo prisões. Nós conseguimos enfraquecer e até chegar aos donos do comércio", comentou. Os policiais aproveitam as prisões para fazer um mapeamento do esquema do tráfico em Americana. "Nós já sabemos, por exemplo, quem são os responsáveis pelas principais biqueiras. São informações que surgem com as prisões desses microtraficantes", disse o policial. O perfil do vendedor de pequenas quantidades de droga é diversificado, conforme avaliam os policiais da DISE. São adolescentes, jovens e até crianças. Um numero cada vez maior de mulheres tem atuado nas 'biqueirinhas' como costuma chamar o delegado. (...)Em americana, as prisões aconteceram no Jardim Guanabara, Vila Bela, Parque da Liberdade, São Roque, São Jerônimo e na Praia Azul. (...) "O Jardim Guanabara, em Americana, por exemplo, aparece como uma das áreas de grande concentração de pequenos pontos de venda de drogas e vamos intensificar nosso trabalho" afirmou Pozzetti.

Cumprе destacar que o local onde o réu foi preso é conhecido como intenso ponto de tráfico de drogas.

O acusado Gustavo negou a prática do delito. Disse que estava no depósito, bebendo e fumando um entorpecente, que tinha acabado de comprar para seu consumo.

No entanto, a versão pueril do réu em juízo, restou isolada no conjunto probatório.

No mais, em que pesem as alegações de uso de entorpecentes, e eventual dependência e/ou internação para tratamento, tal fato, por si só, não impede a ocorrência concomitante do tráfico.

Apelação Criminal- Tráfico de Drogas- Recurso da Defesa- Pedido de Ausência de provas e absolvição- Inviabilidade- Policiais Civil que cumpriam mandado de prisão temporária, em desfavor do réu, e localizaram um tijolo de maconha, pesando 689,12 gramas na residência- Desclassificação para o crime descrito no artigo 28, da Lei de Drogas- Provas suficientes à condenação- Condição de usuário não exclui a de traficante- Responsabilização inevitável- Dosimetria-Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal- Réu reincidente em crime doloso - Redutor - Não cabimento-

Requisitos legais não preenchidos - Afastamento ou redução da pena de multa - Impossibilidade - Regime inicial fechado - Manutenção - Sentença mantida- Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501273-80.2020.8.26.0537; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/06/2021; Data de Registro: 26/06/2021)

Desta forma, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, os objetos e/ou o valor em dinheiro de origem não elucidada permitem a segura conclusão de que o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico, razão pela qual é impossível, ainda, a desclassificação para o consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Incabível. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Inadequada. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos representam perigo maior, atingindo incontáveis usuários, além de apresentarem alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de entorpecentes na rua - Ademais, as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação habitual do apelante à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não se tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a traficância momentaneamente - (...) - Pena e regime mantidos Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº 0002456-25.2017.8.26.0616, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Presença de indícios tipificadores do delito - Apreensão de grande quantidade de entorpecente - Excessivo poder de compra que não se adequa à condição simples do réu - Aplicação dos artigos 12 e 37 da lei 6368/76 - Recurso não provido. (Relator: Gentil Leite - Apelação Criminal n. 161.748-3 - Campinas - 01.09.94)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Ré surpreendida na posse expressiva quantidade de maconha e uma porção de cocaína - Quantidade e natureza da droga que evidencia o objetivo de mercancia - Recurso não provido. (Relator: Segurado Braz - Apelação Criminal n. 161.094-3 - São José do Rio Preto - 16.05.94)

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, e do art. 42, da Lei 11.343/06, tendo em vista que a quantidade e o tipo de droga apreendida, que não pode ser considerada grande quantidade, fixo a pena base no mínimo legal.

Assim sendo, fixo a pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa, para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na segunda fase, é impossível a consideração de qualquer circunstância atenuante, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo. A questão foi abordada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que lança uma pá de cal sobre a

matéria: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Tendo em vista que o réu era tecnicamente primário, e não ficou comprovado que se dedique às atividades criminosas e/ou que integre organização criminosa, nos termos do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, diminuo a pena de 2/3 (dois terços), totalizando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Tema 1139, do STJ: É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06. (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR)

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime prisional deverá ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, letra "c" do CP.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao providenciar o cancelamento de sua Súmula nº 512, assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda.

Nessa linha, consta o julgamento do HC 118.533 do Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E POR TRÁFICO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA AFASTADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 23/6/2016, o HC 118.533/MS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, passou a adotar o entendimento de que "o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda". Posteriormente, a Quinta e a Sexta Turmas do STJ, revendo posição anteriormente adotada, passaram a acompanhar o julgado do STF. Desse modo, a execução penal deve tratar o crime praticado pelo paciente como crime comum, e não como crime de natureza hedionda, para fins de cálculo de possíveis benefícios. Precedentes. 2. Está consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento no "sentido de afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas" (HC n. 471.013/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 16/10/2018). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 547.502/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Ainda, a Resolução nº 5 do Senado, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", inserida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº.11.343/06. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO APLICADA. PEQUENA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRIMARIEDADE E MONTANTE DA PENA QUE ENSEJAM O REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/07/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria,

declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Ademais, quanto à hediondez do crime de tráfico privilegiado, deve-se acompanhar a decisão do plenário do STF, no exame do HC n. 118.533/MS, julgado em 23/06/2016, de Rel. da Ministra Cármen Lúcia, na qual se assentou que o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. - Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. - Ora, tendo em vista o montante de pena aplicada, no caso, e considerando que as circunstâncias fáticas concretas não desbordam do ordinário do tipo - apreensão de apenas 1 porção de cocaína, pesando 2 g, e 7 porções de crack pesando 3 g (fl. 27) - cabível o regime inicialmente aberto de cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, c/c art. 42, da Lei n. 11.343/2006. - Do mesmo modo, no que tange à possibilidade de substituição da pena, o Supremo Tribunal Federal, em 1º/09/2010, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 33, e do art. 44, ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes. - No caso, estabelecida a pena-base no mínimo legal e considerando a primariedade do paciente e a quantidade mínima das drogas apreendidas, também faz jus o acusado à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP. - Habeas corpus não conhecido. - Ordem concedida, de ofício, para readequar o regime prisional inicial do paciente para a modalidade aberta e substituir a pena corporal por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juiz singular. (HC 459.796/SP, Rel. Ministro REYNALDO OARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019)

Desse modo, cabe ao Julgador verificar a possibilidade de aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, por estarem ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu GUSTAVO ELIAS BRITO DA SILVA, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis), dias-multa, fixado no piso, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006.

Nos termos dos artigos 43 e seguintes, do Código Penal, em especial os incisos I e IV, do art. 43, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, na forma de prestação de serviços à comunidade, por igual período ao da pena privativa de liberdade, a ser definida pelo Juízo das Execuções, e em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade filantrópica do Município.

Ainda, nos termos do que dispõe o artigo 63 da Lei 11.343/2006 determino a perda dos bens e valores apreendidos, em favor da União, devendo se proceder consoante os parágrafos do mencionado artigo após o trânsito em julgado da presente sentença.

Por fim, considerando ser o réu assistido pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-o das custas.
P.I.C.

Americana, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA